

1500048-55.2022.8.26.0569

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 06/10/2022

... droga, informando que destinava-se ao tráfico, em razão de passar por dificuldades financeiras. Em revista pessoal, encontraram a quantia de R\$ 10,00, fracionado em duas cédulas de R\$ 5,00. Maurício disse que Carolina recolhia o dinheiro e trabalhava num bar nas proximidades. Os agentes foram até o bar, indagada, Carolina negou o tráfico de drogas ou associação para tal ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500048-55.2022.8.26.0569 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500048-55.2022.8.26.0569

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2004520/2022 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 22294749 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 57/22/610 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2004520 - DEL.POL.SALTO, 57/22/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURÍCIO TAVARES DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra o réu MAURÍCIO TAVARES DA COSTA, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, c.c. o art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal porque, em tese, 05 de janeiro de 2022, por volta das 21h01min, na Rua Albânia, nº 384, Jardim das Nações, nesta Cidade e Comarca de Salto/SP o acusado, em ocasião de calamidade pública, trazia consigo e guardava para entrega a consumo e fornecimento a terceiros, ainda que gratuito: a) 96 (noventa e seis) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 52,82g (cinquenta e dois gramas e oitenta e dois centigramas); b) 13 (treze) porções de "cocaína", em sua forma petrificada, popularmente conhecida como "crack", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 1,70g (um grama e setenta centigramas); e c) 06 (seis) porções de "cocaína", acondicionadas em microtubos plásticos, com peso líquido de 3,71g (três gramas e setenta e um centigramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O réu foi notificado pessoalmente e apresentou defesa escrita (fls. 100-102).

A denúncia foi recebida em 15 de julho de 2022 (fls. 109-110).

Durante a instrução processual o réu foi interrogado e foram inquiridas duas testemunhas comuns.

Nas alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação do réu, nos termos da denúncia, aplicação da pena acima do mínimo legal em virtude da anterior prática de ato infracional e quantidade de droga apreendida, regime inicial de cumprimento semiaberto e afastamento do redutor previsto no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas. A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por inexistir prova suficiente para a condenação, reconhecimento da atenuante da menoridade, reconhecimento do redutor contido no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, regime inicial de cumprimento de pena aberto e a concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-05), auto de exibição e apreensão (fl. 13-14), auto de constatação preliminar (fls.15-16) e laudo de exame químico toxicológico (fls.68-72), bem como por toda prova oral coligida nos autos.

As testemunhas de acusação Robson Silveira Barbosa e Ronaldo Siqueira de Melo, guardas municipais, afirmaram que estavam em patrulhamento e, em local conhecido por ser ponto de tráfico, viram Maurício agachado, segurando uma sacola branca. Ao perceber a presença da viatura, ele largou a sacola no local e fugiu. Na abordagem localizaram 06 (seis) microtubos de cocaína. Após busca no local onde Maurício havia sido visto, recuperaram a sacola plástica e localizaram mais 96 (noventa e seis) microtubos, de cor roxa, semelhantes aos encontrados nas proximidades da abordagem de Maurício, bem como microtubos de cores amarelas, todos contendo substância semelhante à cocaína, e ainda 13 (treze) microtubos de crack. Maurício assumiu a posse da droga, informando que destinava-se ao tráfico, em razão de passar por dificuldades financeiras. Em revista pessoal, encontraram a quantia de R\$ 10,00, fracionado em duas cédulas de R\$ 5,00. Maurício disse que Carolina recolhia o dinheiro e trabalhava num bar nas proximidades. Os agentes foram até o bar, indagada, Carolina negou o tráfico de drogas ou associação para tal finalidade. Realizada a revista pessoal em Carolina, nada de ilícito localizado. Encontraram R\$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) em cédulas fracionadas, acerca da origem do dinheiro, que seria proveniente de caça-níquel. Os moradores e usuários de drogas que circulam no local informam que o réu continua a gerenciar a venda de drogas.

Interrogado judicialmente, o réu disse que portava apenas três pinos de cocaína destinados ao seu uso. A droga que estava na sacola não era dele.

Os policiais apresentaram versão firme e coerente demonstrando que o réu estava agachado, manuseando uma sacola plástica e, ao perceber a presença da viatura, dispensou a sacola e empreendeu fuga a pé, sendo detido logo depois. Foram localizados entorpecentes próximo da abordagem e no interior da sacola plástica dispensada que foi posteriormente recuperada pelos agentes.

As declarações de policiais e guardas municipais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese. Além disso, cuida-se de crime permanente e guardas municipais podem realizar prisão em flagrante, observado o artigo 301 do CPP.

Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido tem-se a jurisprudência:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

A versão do réu de que assumiu, na fase policial, a propriedade da droga contida na sacola plástica para evitar a atribuição da traficância a uma terceira pessoa não possui qualquer amparo na prova produzida nos autos. A respeito do ônus da prova em relação a fato novo suscitado pelo réu, confira-se a afirmação de Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Com efeito, o estado de emergência sanitária não facilitou a execução da conduta delituosa. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Defesa pretende a redução da pena, afastamento da agravante do delito praticado durante a pandemia do COVID-19, compensação das atenuantes com a recidiva e o abrandamento do regime prisional. Parcial acolhimento. Autoria e materialidade sobejamente comprovadas sequer foram objeto do recurso defensivo. Prisão em flagrante. Réu confesso. Seguro relato das testemunhas descrevendo a dinâmica criminoso e imputando ao acusado a responsabilidade pelos fatos narrados na denúncia. Condenação inevitável. Dosimetria comporta reparos. Na segunda etapa, necessário afastar a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal. Da mesma forma, imperioso compensar as atenuantes da confissão e da menoridade relativa com a agravante da reincidência. Súmula 545 do E. STJ. Impossível a concessão do privilégio. Regime fechado decorre de expressa determinação legal e foram devidamente fundamentados nos autos. Súmulas nº 718 e 719 do C. STF e 440 do e. STJ. Inviável a substituição por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido" (TJSP: Apelação Criminal 1512067-20.2020.8.26.0228; Relator (a): ANDRADE SAMPAIO; Órgão Julgador: 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Barra Funda, 32ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/02/2021; Data de Registro: 13/02/2021). O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 56,53g (cinquenta e seis gramas e cinquenta e três centigramas) de cocaína e 1,70g (um grama e setenta centigramas) de crack, o réu é primário (fls. 108) e não restou provado que ele integra organização criminoso, considerando que a prisão decorreu de abordagem de agentes da guarda municipal, sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo.

Finalmente, respeitado o entendimento do Ministério Público, a anterior prática de ato infracional não pode ser considerada para fins de antecedentes ou reincidência, portanto, não afasta a possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado. Nesse sentido tem-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRESENTE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PRÁTICA DE ATOS INFRACIONAIS. IRRELEVÂNCIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso

ou revisão criminal, ressalvado, nesta última hipótese, serem os fatos incontroversos e presente situação excepcional de flagrante ilegalidade ou teratologia que autorize a concessão da ordem de ofício. Precedente. 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a existência de registro pretérito de atos infracionais não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes. 3. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a quantidade de drogas não expressiva, bem como ausentes fortes indícios de envolvimento com organização criminosa ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, no patamar de 2/3 (dois terços), inexistente, ainda, circunstância ou fato desabonador ensejador de aplicação de fração menor. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 214089 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 3. Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. 4. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, figura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. 5. Agravo regimental desprovido.

(HC 202574 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presente a atenuante da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput",

inc. III, do Código Penal, com os fundamentos antes apontados para reconhecimento da inconstitucionalidade da norma de vedação, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu MAURÍCIO TAVARES DA COSTA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa sendo a pena privativa de liberdade substituída nos moldes determinados acima.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Arcará o réu ainda com o pagamento das custas processuais (Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, artigo 4º, §9º, alínea "a"), com as ressalvas da lei de assistência judiciária, que ora lhe concedo. Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP a advogada dativa, para retirada exclusivamente pela internet. Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA